

1500323-68.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Comarca: Monte Aprazível

Foro: Foro de Monte Aprazível

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Aprazível

Foro de Monte Aprazível

2ª Vara

Rua Monteiro Lobato, nº 269, Monte Aprazível - SP - cep 15150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500323-68.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500323-68.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eliaque Santos de Jesus

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Vistos.

ELIAQUE SANTOS DE JESUS, vulgo "Baiano", qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº.

11.343/2006, porque no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 23h20min., na Rua Campos Sales, número 258, centro, na cidade de Poloni, integrante desta comarca, em tese, trazia consigo e guardava 02g de cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, e 02g de cocaína, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de fornecer ou entregar as substâncias ilícitas ao consumo de terceiros.

A denúncia teve por base o inquérito policial e, após defesa preliminar (fls. 163/167), foi recebida no dia 20 de maio de 2022 (fls. 171/172).

O réu foi citado (fls. 214).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas e o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por considerar provadas autoria e materialidade. A defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 e pela aplicação ao caso da causa de diminuição de pena veiculada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu sob os auspícios do contraditório e da ampla

defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

À mingua de preliminares de ordem processual, passo diretamente ao exame do mérito da causa, constatando que a materialidade delitativa foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudo de constatação (fls. 18/20), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 88/90).

A autoria é certa e indubitosa.

Ouvidos em juízo, os policiais militares Edvaldo Alves Barbosa e Evaristo Luiz de Faria Santos, em uníssono, assinalaram que faziam patrulhamento na cidade de Poloni quando avistaram dois indivíduos. William passava algo a Eliaque, ou o contrário, o que chamou atenção. Feita abordagem, Eliaque tinha drogas consigo e William dinheiro. William disse que compraria droga de Eliaque, que confirmou a situação. Eliaque revelou que já tinha passagem por tráfico e aludiu ao preço cobrado por cada porção de droga. As porções apreendidas estavam no bolso da bermuda do réu, em porções individuais, embaladas em plástico. A abordagem ocorreu na rua. William Pablo Garrido Novaes, também inquirido sob o crivo do contraditório, confirmou que, de fato, estava no local da abordagem para adquirir maconha do acusado.

Não há dúvidas, destarte, de que o réu fora efetivamente surpreendido trazendo entorpecente consigo, conduta que se amolda ao tipo imputado.

Importante consignar, na esteira de entendimento corrente, que o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, tratando-se de prova apta a amparar a condenação, sobretudo no presente caso, em que não paira sobre as testemunhas, de forma fundada e concreta, qualquer suspeita de parcialidade ou inidoneidade.

Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os depoimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais.

Nesse sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

A versão dos fatos apresentada pelo acusado em seu interrogatório, no sentido de que foi agredido injustamente pelos policiais, ameaçado e até levado a um canavial, não encontra eco em nenhuma prova concreta, calhando consignar que William Pablo, também em tese levado ao tal local, nada disse sobre isso, assim como que o laudo de fls. 31, elaborado no dia da prisão, não apurou qualquer lesão.

Encontrando-se bem elucidado que a propriedade de todo o entorpecente apreendido realmente deve ser atribuída ao denunciado, o intuito mercantil e, por conseguinte, a traficância, exsurtem evidentes, à luz dos critérios elencados no artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Nesse particular, observo que a quantidade de substância ilícita arrestada, especificamente no que toca ao número de porções (aproximadamente quinze no total), a despeito do baixo peso, supera aquilo que normalmente se encontra na posse de um simples usuário.

É o traficante, frise-se, no exercício de seu negócio, quem corre o risco de circular em público com elevada monta de entorpecente. O simples usuário, regularmente, tem consigo somente o necessário para o uso imediato ou iminente.

A forma de acondicionamento da droga também delata a posição de traficante do increpado, já que o entorpecente estava individualmente embalado e pronto para a entrega em varejo.

Aponta, ainda, para a traficância o fato de o acusado ter consigo dois tipos

diferentes de substâncias ilícitas. Sendo o tráfico um negócio, à evidência, o agente criminoso sempre procura aumentar seu rol de consumidores expondo à venda a maior variedade possível de drogas, atendendo ao gosto de cada usuário.

A fala de William Pablo, por fim, sacramenta todos os pontos levantados, cumprindo reiterar que ele estava no local exatamente para comprar drogas do acusado.

Não se está aqui simplesmente conjecturando, impende obtemperar. Está-se apenas extraíndo conclusão lógica de circunstâncias conhecidas e provadas que, relacionadas ao fato, por indução, autorizam a inferência da existência de outras circunstâncias (artigo 239, do Código de Processo Penal).

Pertinente a citação do escólio de Guilherme de Souza Nucci sobre o referido artigo 239, do Código de Processo Penal:

"(...) os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação, quanto para a absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descuidar que há muito preconceito contra essa espécie de prova, embora seja absolutamente imprescindível ao Juiz utilizá-la. Nem tudo se prova diretamente, pois há crimes camuflados – a grande maioria – que exigem a captação de indícios para a busca da verdade real" (Código de Processo Penal Comentado. 12. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 555).

De se ressaltar que eventual condição de usuário do acusado, por si, não tem o condão de afastar as ilações ora tomadas, eis que as particularidades da ação criminosa e as circunstâncias da prisão justificam a responsabilização pelo crime de tráfico.

Aliás, a rotina forense demonstra que, corriqueiramente, as figuras do traficante e do usuário acabam imbricadas, de maneira que o agente, além de dedicar-se ao comércio espúrio, acaba consumindo parte do produto ilícito.

Nesses casos, como vem pacificamente entendendo a Egrégia Corte Bandeirante, impõe-se a responsabilização pela conduta mais grave:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP, 101/498);

"Pouco importa, de resto, se o apelante é usuário ou não, pois viciado, quando trafica, deve responder pelo crime mais grave, que se consuma com o mero porte da substância entorpecente, para o fim de entrega a terceiros, independentemente da ocorrência de qualquer ato de comércio." (TJSP - AC 896.821.3/8-00, Rel. René Ricupero J. 30.11.2006).

O fato de não ter sido o increpado flagrado efetuando, exatamente (William Pablo disse que ainda na havia tratado com o réu o preço), a comercialização de entorpecente não compromete a materialização do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Como se sabe, o tipo penal em análise constitui delito de ação múltipla ou conteúdo variado, perfazendo-se com a realização de qualquer dos verbos nele descrito, os quais não se encontram submetidos a regime cumulativo.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 20, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

Na hipótese, consoante já exaustivamente explanado, o acusado trazia consigo considerável número de porções de substância ilícita, evidenciando o contexto que o tóxico seria entregue ao consumo de terceiros.

Encerrando a tipificação, destaco a aplicabilidade à espécie da causa de diminuição de pena trazida pelo § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, já que o réu é primário e não ostenta antecedentes que possam ser validamente considerados em seu desfavor (vide fls. 188), inexistindo no processo qualquer elemento de prova que indique de forma segura sua dedicação habitual a atividades criminosas ou sua participação em organização criminosa.

Registro que a existência de processos em curso, sem culpa formada sequer em primeira instância, não tem o condão de gerar nenhum efeito nestes autos. Assim, afastadas as teses defensivas, comprovadas autoria e materialidade e não incidindo causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/06. Passo, pois, a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Para fixação da pena-base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais, tanto as genéricas, veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal, como as específicas para o delito em análise, insculpidas no artigo 42, da Lei de Tóxicos. Nesse mister, não obstante primário, a ré trazia consigo, para venda, cocaína, substância altamente viciante e apta a promoverem a rápida degradação física e psíquica do usuário, conjuntura que imprime elevado grau de censurabilidade à sua conduta perpetrada. Desse modo, pela natureza de um dos entorpecentes traficados, impor-se-ia a majoração da pena-base. Entretanto, para evitar o bis in idem vedado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 666.334/MG em sede de repercussão geral (Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 3/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), deixo de considerar o fator apontado nesta etapa, fixando a pena-base, logo, no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nada havendo a ser considerado na segunda fase da dosimetria, resta aqui inalterada a pena.

Por fim, conforme fundamentação anteriormente exarada, há que se dar aplicação à causa de diminuição de pena insculpida no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. Anotando que a mensuração da redução deve ser realizada à luz das circunstâncias judiciais (quer as gerais, previstas no artigo 59, do Código Penal, quer as especiais, previstas no artigo 42, da Lei 11.343/06) e que uma das drogas comercializadas se revestia de natureza extremamente danosa, minoro a pena da acusada em 1/2 (metade), chegando-se ao montante final de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Inexistindo nos autos elementos que forneçam parâmetros seguros para a aferição da condição econômica do réu, fica o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Em observância ao entendimento esposado pelo plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos habeas corpus n.º 111.840 (Rel. Min. Ministro Dias Toffoli, j. 27.6.2012) e 118.533/MS (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016), o regime inicial, tratando-se de pena de reclusão inferior a quatro anos aplicada a réu primário, será o aberto, na esteira do que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Saliento, alterando entendimento anterior, que a fixação da pena-base no patamar mínimo obsta a imposição de regime prisional mais gravoso do que o legal, por aplicação da súmula 440, do C. STJ.

Outrossim, à luz da posição recentemente adotada pelo C. STF (habeas corpus nº 97.256/RS, cujos efeitos foram ampliados pela Resolução nº 5/2012, do Senado Federal), não envolvendo o crime violência ou grave ameaça contra pessoa, não ultrapassado o limite de quatro anos e fixado regime inicial aberto para expiação, revela-se socialmente recomendável a utilização de reprimenda alternativa, notadamente diante de seu elevado potencial ressocializante, pelo que, reputo presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda substituída, devendo o serviço ser especificado pela E. Vara das Execuções Criminais, além do pagamento de mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, fazendo-o para condenar ELIAQUE SANTOS DE JESUS, vulgo "Baiano", devidamente qualificado nos autos (fls. 08/11]), como incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão

em regime inicial aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, ficando a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída, que deverão ser especificados pela E. Vara das Execuções Criminais competente, e pelo pagamento de mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

As multas deverão ser pagas em 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 50 do Código Penal, observada a disposição constante do artigo 49, § 2º, do mesmo Codex.

Insubsistentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, mediante cumprimento das medidas cautelares impostas na decisão de fls. 47/49, que terão validade até o trânsito em julgado.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, na forma do artigo 50, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 11.343/06. Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não possui vítima certa.

Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03). Concedo à ré, patrocinada por defensor dativo indicado pela OAB-SP em decorrência de convênio mantido com a DPE-SP, o benefício da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se na forma do artigo 63, § 4º, da Lei 11.343/06 e do Comunicado CG nº 805/2019, com relação aos bens e valores declarados perdidos em favor da União, oficie-se para suspensão dos direitos políticos dos acusados enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo, de acordo com os atos praticados, para retirada exclusivamente pela internet.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Registre-se, se o caso.

Cumpra-se.

Monte Aprazível, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA